

1500201-19.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. A prática do tráfico nas imediações de igreja ou entidade religiosa não está prevista no dispositivo majorante e a sua inclusão importa em analogia "in malam partem", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500201-19.2022.8.26.0592 - Controle 2022/001022

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DIAS DA GAMA e outro

Aos 14 de outubro de 2022, às 14:00h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça RODRIGO DE ANDRADE FÍGARO CALDEIRA, do(a) Dr(a). Defensor BRUNO FÉLIX DE PAULA, do Dr. Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e dos réus. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado às Defesas o direito de contato reservado com os réus através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e, ao final, os réus foram interrogados sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Pela Defesa do réu Guilherme foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Messias e Jeissielen, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou mediante sistema de gravação. Dada a palavra a Defesa do réu John Lenon, assim se manifestou: "MM. Juiz(a), JOHN LENON PEREIRA DA SILVA foi denunciado pela infração, em tese, ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, pois supostamente, mantinha consigo para posterior venda, substâncias de uso proscrito. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. As testemunhas policiais RENATO FERNANDES FANTES e ALAN GONÇALVES FERREIRA, em seus depoimentos, afirmaram que

estavam em patrulhamento, quando avistaram os acusados em uma moto e, ao perceberem que um deles tentou esconder algo na cintura, passaram a persegui-los. Em dado momento, os acusados tentaram fugir, despistando a polícia, oportunidade em que foram perseguidos até se chocarem contra calçada e caírem. Ao serem revistados, foram encontrados 45 pinos de "crack" com o acusado John Lenon. Em decorrência disto foram presos em flagrante e conduzidos a delegacia. O acusado, GUILHERME DIAS DA GAMA, em seu interrogatório, afirmou que desconhecia que o acusado John estava portando drogas, que apenas tentou fugir por estar dirigindo sem habilitação. Alega também que, após ter cumprido pena, não se envolveu mais com qualquer tipo de ato ilícito, que trabalha em uma serralheria, devidamente registrado. O acusado JOHN LENON PEREIRA DA SILVA, em seu interrogatório, afirmou que estava usando entorpecentes com o acusado GUILHERME. Que o convidou para andar de moto e ver o movimento. Que, em dado momento, com receio da polícia, GUILHERME, que estava dirigindo sem habilitação, tentou fugir. Posteriormente, os acusados foram parados e, devidamente revistados, nada teria sido encontrado.

1. DA ILICITUDE

PROBATÓRIA Abordagem fundada apenas na atitude suspeita. Impossibilidade.

Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: É preciso reconhecer que, no caso em análise, a apreensão das drogas derivou de uma atuação ilícita dos policiais militares, tendo em vista que amparada na simples constatação de uma "atitude suspeita" de dois indivíduos em uma motocicleta, o que não configura o flagrante e, por isso, torna ilícitos por derivação os elementos de prova daí decorrentes (CF, art. 5º, LVI e CPP, art. 157, § 1º). Nesse ponto, rememore-se que o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, prescreve que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". Em sentido aproximado, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.3 prescreve que "Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários". Já o art. 9.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estipula que "Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos".

Perceba-se, por conseguinte, que o ordenamento nacional protege o jurisdicionado contra detenções arbitrárias, estabelecendo que alguém somente poderá ser preso em conformidade às hipóteses previstas em lei. Nesse sentido, em se tratando de prisão em flagrante, o Código de Processo Penal, art. 302, assim define a situação de flagrância: "Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração". Se é assim, a prisão em flagrante somente se legitima quando constatada alguma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal. Nesse trilho, em se tratando de norma que interfere na liberdade individual, impõe-se a sua interpretação taxativa. Por isso, não se pode admitir uma detenção que não se pautar em critérios legalmente estipulados, amparando-se em uma suposta "atitude suspeita" ou em suposto "nervosismo" demonstrado pelo cidadão. Do contrário, estar-se-á diante de uma detenção ilegal, arbitrária. Nesse sentido, já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Fernández Prieto e Tumbiero vs. Argentina, sentença de 1/9/2020, tradução livre, §§ 81 e 82). Por via de consequência, no caso ora analisado, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem. Nesse diapasão, os policiais não presenciaram a prática do crime e não presenciaram o acusado em situação de flagrante presumido/impróprio (CPP, art. 302, III e IV), visto que efetuaram a abordagem por conta de uma singela "atitude suspeita", uma vez que, diante de seus próprios relatos, os denunciados estavam na rua, quando, durante o patrulhamento, decidiram realizar a abordagem pessoal, com base em uma tentativa de esconder algo por parte do acusado. Assim, a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a indevida abordagem. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá

ser desentranhado dos autos, visto que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, como consequência, o laudo de constatação e o laudo definitivo deverão ser reconhecidos como provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial. Vale dizer: tais elementos mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao acusado. Se é assim, impõe-se, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal, a reforma da r. sentença e a consequente absolvição do apelante. 2. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório, verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial. Como se pode observar, na fase judicial, muito pouco se produziu a respeito da dinâmica dos fatos, restando apenas a reprodução dos relatos obtidos em solo policial, os quais, isoladamente, não são suficientes para sustentar um decreto condenatório. A única circunstância que sustenta o presente procedimento é a diminuta quantidade de droga, que supostamente teria sido encontrada com o acusado, e o depoimento dos policiais que procederam à abordagem. Ademais, os relatos oferecidos pelos Policiais, contrariamente ao que ocorre com os demais cidadãos, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que os agentes da lei tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Isso posto, percebe-se que o conjunto probatório é frágil, não se podendo constatar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do apelante. Há, no mínimo, dúvida acerca da imputação. Dessa forma, o interrogatório do acusado se coaduna com a prova oral produzida em juízo. Analisando o conjunto probatório, é forçoso reconhecer a absoluta falta de provas para a condenação, sendo de rigor a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Sendo assim, diante da fragilidade probatória, pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do CPP. No mais, por força do princípio da presunção da inocência – insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa haver condenação penal, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Com efeito, faz mister a presença de um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório, o que, todavia, não ocorre na hipótese dos autos. Não restando, dessa forma, comprovado o fato típico do art. 180, “caput”, do Código Penal. De rigor, portanto, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII do

Código de Processo Penal. 3. DA DECLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS: Em atendimento aos princípios da eventualidade e da ampla defesa, requer-se a desclassificação de referida imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que inexistem quaisquer provas seguras, com a precisão exigida pelo Direito Penal, de que a droga apreendida não fosse para uso próprio. Ainda nesse sentido, frise-se que o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, dispõe que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (grifamos). Percebe-se, assim, que um dos elementos decisivos para a diferenciação entre o mero usuário e traficante, é a quantidade de drogas encontradas em poder do imputado. Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam mais bem enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida em poder do acusado é pequena, corroborando suas declarações no sentido de que é usuário. Nesse sentido, é certo que a imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 seria demonstrada apenas com base nos depoimentos dos policiais militares, elementos de prova de

fraco teor de convicção. Assim, não demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020. Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL: Em caso de condenação, impõe-se a aplicação da pena base seja fixada no mínimo na primeira fase de dosimetria, considerando-se as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal. Diga-se, ainda, que muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é evidente que. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Além disso, a quantidade de drogas encontrada apreendida é ínfima e certamente não serve para configurar o aumento pleiteado pela acusação, pelo que requer sua fixação no mínimo legal. Fixação do regime inicial menos gravoso (semiaberto) para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, considerando a ausência de circunstâncias pessoais e objetivas desfavoráveis (Súmulas 440 e 269/STJ; 718 e 719/STF). 5. A concessão do direito de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312): De acordo com a lição de EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA, "[...] (probabilidade de fuga) e outra (a probabilidade de condenação) não são suficientes para, por si só, justificam a prisão, dado que nenhuma delas atende a exigência constitucional, expressa na seguinte norma: ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5, LXI)". Nesses termos, considerando ainda que o acusado respondeu ao processo em liberdade, não nenhuma circunstância nova que autorize a sua prisão nesse momento processual.". Dada a palavra a Defesa do réu Guilherme, se manifestou mediante sistema de gravação. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de Guilherme Dias da Gama e de John Lenon Pereira da Silva, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006. Segundo consta na denúncia de fls. 169/171, *ipsis litteris* (negritos ora apostos): Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 17h30min, na rodovia vicinal Antônio Lovato, km 01, área rural, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, GUILHERME DIAS DA GAMA, qualificado a fls. 23 e JOHN LENON PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 41, agindo em concurso, com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para posterior entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e cinco) "eppendorfs" contendo "CRACK", com peso líquido de 3,9g (peso bruto de 31,2g), cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudos de constatação de fls. 18/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. É dos autos que os denunciados, em conjunto e unidade de propósitos, decidiram praticar o tráfico de drogas nesta cidade, e, para tanto, as substâncias eram fornecidas por pessoas não identificadas e mantidas em poder dos denunciados, para depois serem comercializadas ao consumo de terceiros. Conforme consta dos autos, os denunciados traziam consigo e transportavam 45 (quarenta e cinco) porções de "crack" para a comercialização, porém, enquanto trafegavam de motocicleta pela rodovia vicinal Antônio Lovato, sentido Distrito de Parnaso à Tupã, na altura da "Cohab Nem", foram vistos pela guarnição da Polícia Militar que seguia em sentido contrário, e nesse momento o denunciado JOHN LENON, que era levado como passageiro, escondeu algo na cintura. Sucede que os policiais militares fizeram o retorno e passaram a acompanhar o motociclo, oportunidade em que o denunciado GUILHERME, que era condutor, acelerou a moto e adentrou num bairro novo existente naquele local, prosseguindo-se então o acompanhamento com acionamento de reforço policial. Na sequência, os denunciados acabaram chocando a motocicleta contra a borda do passeio público e ambos foram ao

solo. Os milicianos procederam à abordagem dos increpados, sendo encontrado com o passageiro JOHN LENON no interior das vestes íntimas, um saco plástico contendo 45 (quarenta e cinco) "eppendorfs" de "crack", bem como com GUILHERME uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais). Os denunciados, que já eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas, foram apresentados na repartição policial e autuados em flagrante delito pela Autoridade Policial. As drogas foram apreendidas e submetidas a exame pericial de fls. 18/20, confirmando tratar-se da perigosa droga "CRACK". Observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento, o dinheiro apreendido, a natureza da droga, o fato de terem tentado furtar-se à ação policial, seja inicialmente escondendo os entorpecentes sob as vestes e posteriormente tentando fugir da abordagem policial com a motocicleta, os envolvimento de ambos com a traficância, aliadas as versões dos policiais e as circunstâncias da prisão, são elementos indicativos de que os autuados estavam agindo imbuídos no mesmo propósito da traficância, desenvolviam o tráfico ilícito de entorpecentes na oportunidade, e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros.

Inquérito policial e diligências às fls. 01/163. Oferecimento da denúncia às fls. 164/171. Manutenção da prisão preventiva conforme peças às fls. 172/191 e 221/235. Defesas prévias às fls. 198/204 e 218/220. Recebimento da denúncia às fls. 236/238. Expediente de intimações e providências diversas às fls. 239/401. Audiência nesta data. O Ministério Público reiterou o pleito condenatório. As defesas pugnaram nulidade por ausência de justa causa para a efetivação da abordagem. Quanto ao mérito, postularam a absolvição por fragilidade do acervo. Arguíram que não há provas suficientes das condutas imputadas. Impugnaram a palavra dos policiais e a apreensão de drogas. Em caso de condenação, protestaram por pena mínima e regime inicial menos gravoso.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, em que pese a alegação de nulidade por ausência de justa causa para a abordagem, entendo que não há qualquer elemento nos autos para fundamentar o deferimento. Com efeito, a abordagem decorreu de condução de veículo de forma anormal, tendo o passageiro se portado de forma suspeita, ao tentar esconder algo. Não obstante, as manifestações dos Policiais encontram guarida nas manifestações dos acusados, os quais relataram que o condutor do veículo efetivamente se evadiu ao perceber a presença dos policiais militares, fundamentando a evasão por ausência de documentação veicular. Entendo portanto que tanto a conduta do passageiro do veículo, quanto a conduta de evasão do condutor, trafegando pelas vias tentando escapar das autoridades policiais, são fatos concretos que legitimam a autuação policial, não havendo qualquer ilicitude a ser reconhecida.

No tocante a eventual violência policial, observo que os réus foram submetidos a atendimento médico e a audiência de custódia, momentos nos quais se mostra possível aferir administrativamente eventual excesso por parte dos policiais militares. Entendo que tais fatos, por si só, não são suficientes para declarar nulidade dois elementos probatórios carregados aos autos, motivo pelo qual indefiro o requerimento de nulidade.

Quanto ao mérito, em que pese a combatividade das ilustres defesas em seus memoriais finais, cumpre destacar que o integral acolhimento da pretensão punitiva desvela-se insofismável, porquanto estão provadas, à saciedade, a autoria e a materialidade delitivas da conduta típica imputada, nos termos doravante esposados. Com efeito, a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente provadas nos autos, de acordo com o auto de prisão em flagrante delito (fls. 01 e ss), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudos periciais (fls. 18/20), comprovante de depósito judicial (fls. 154/155 e 402/405), relatório final do Delegado de Polícia (fls. 157/161), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A testemunha RENATO FERNANDES FANTES, policial militar ouvido na fase inquisitiva às fls. 02, declarou ipsis litteris o seguinte: que nesta data encontra-se em serviço e patrulhava na companhia do Cb. Alan, pela Vicinal Pioneiro Antônio Lovato, sentido Parnaso/Tupã, quando, na altura da "Cohab Nem", depararam-se com

uma motocicleta com dois ocupantes, que trafegava em sentido oposto, sendo, ao avistar a viatura, o garupa tentou esconder algo na cintura, motivando a abordagem; assim sendo, fizeram o retorno e passaram a acompanhar o motociclo, cujo condutor aumentou a velocidade, sendo o reforço acionado, via rádio; o motociclista adentrou a um bairro novo ali existente, ainda sendo acompanhado, e acabou por chocar o veículo contra a borda da calçada, tendo os ocupantes caído ao solo; logo após, foram abordados, sendo que, durante a revista pessoal, foi localizado na veste íntima do garupa, JOHN LENON, um saco plástico contendo em seu interior 45 (quarenta e cinco) "eppendorfs" com substância aparentando ser "crack", e com o motorista, GUILHERME, uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais); indagados, JOHN LENON permaneceu silente, e GUILHERME, por sua vez, afirmou que estava em uma praça quando o "colega" JOHN LENON, que conheceu na "cadeia", chegou e o convidou para "fazer uma fita na Nem" (sic), tendo o mesmo aceito, sem indagá-lo sobre qual seria a "fita", alegando desconhecer que o garupa estava na posse de drogas; em razão das escoriações decorrentes da queda, os abordados foram levados à Unidade de Pronto Atendimento, onde foram consultados, medicados e liberados, sendo então conduzidos a este Plantão Policial, algemados, por fundado receio de fuga; esclarece que, em consulta aos antecedentes criminais dos indivíduos, constatou que ambos são egressos do sistema prisional pela prática do delito de tráfico de drogas, e tem conhecimento de que JOHN LENON foi preso há cerca de duas semanas, também pela prática do mesmo crime, por outra equipe da Polícia Militar.. Em Juízo, RENATO declarou que no dia dos fatos estava realizando patrulhamento no distrito de Parnaso quando, ao retornar para Tupã, deparou-se com uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Esclareceu que o "garupa" fez movimento compatível que esconder um objeto entre as pernas. Diante de tal fato foi realizado o procedimento de abordagem. Foram dados os sinais de parada e luminosos, sendo desrespeitados pelo condutor. Somente foi possível a abordagem após o acidente. Durante a busca pessoal, somente foi encontrado dinheiro em espécie na posse do acusado Guilherme. Na posse do acusado John Lennon foram encontrados 45 porções de entorpecentes conhecidas como crack. Em entrevista o réu Guilherme teria mencionado que encontrou o correu em local publico tendo combinado em fazer uma "fita". Informou que o acusado Guilherme teria dito que desconhecia a existência de eventual entorpecente pertencente ao corréu John. Ambos se machucaram pela queda da motocicleta. A testemunha ALAN GONÇALVES FERREIRA, policial militar ouvido na fase inquisitiva às fls. 03, declarou ípsis litteris o seguinte: que nesta data encontra-se em serviço e efetuavga patrulhamento, juntamente com o Sgt. Fantes, pela Vicinal Pioneiro Antônio Lovato, sentido Parnaso/Tupã, quando, na altura da "Cohab Nem", avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, que trafegava em sentido oposto, sendo, ao ver a viatura, o garupa tentou esconder algo na cintura, fato que motivou a abordagem; assim sendo, fizeram o retorno e passaram a acompanhar o citado veículo, cujo condutor aumentou a velocidade, sendo o reforço acionado, via rádio; o motociclista adentrou a um bairro novo ali existente, ainda sendo acompanhado, até que se chocou contra aborda da calçada, tendo os ocupantes caído ao solo; em seguida, foram abordados, sendo que, durante a revista pessoal, foi encontrado na veste íntima do garupa, JOHN LENON, um saco plástico contendo em seu interior 45(quarenta e cinco) "pinos " com substância aparentando ser "crack", e com o motorista, GUILHERME, uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais); questionados, JOHN LENON permaneceu silente, enquanto GUILHERME relatou que estava em uma praça quando o "colega" JOHN LENON, que conheceu na "cadeia", chegou e o convidou para "fazer uma fita na Nem" (sic), ao que aceitou, sem indagá-lo sobre qual seria a "fita", alegando desconhecer que o garupa estava na posse de drogas; em razão das escoriações decorrentes da queda, ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento, onde foram consultados, medicados e liberados, sendo então conduzidos a este Plantão Policial, algemados, por fundado receio de fuga; por derradeiro, informa que, em consulta aos antecedentes criminais dos indivíduos, foi constatado que ambos são egressos do sistema prisional pela prática do delito de tráfico de drogas, e tem conhecimento de que JOHN LENON, conhecido nos meios policiais, foi preso há cerca de duas semanas, também pela prática do mesmo crime, por outra equipe da Polícia Militar. Em Juízo, ALAN disse que na data dos fatos estava em

patrulhamento no Distrito de Parnaso quando avistaram uma motocicleta vindo em direção contrária. Esclareceu que foram dados sinais de parada e sonoros, contudo o condutor se evadiu pela comarca, somente sendo abordados após um acidente. Durante a abordagem, em revista pessoal, encontraram 45 porções de crack na posse do réu John Lennon. Foram encontrada a quantia de R\$20,00 na posse do corréu Guilherme. Em entrevista, o acusado Guilherme negou a prática delitiva tendo apenas tendo sido convidado para passear pela cidade.

O acusado Guilherme Dias da Gama, ouvido na fase inquisitiva às fls. 04, declarou *ipsis litteris* o seguinte: QUE que não se faz acompanhar de advogado e que sua convivente Jeicielem Silva Santos foi cientificada de sua prisão, através do celular (18) 99121-5707, fazendo-se presente nesta Unidade Policial; quanto aos fatos, afirma que discorda da versão apresentada pelos policiais militares, pois em nenhum momento disse aos mesmos que iria participar de uma "fita", desconhecia que seu colega JOHN LENON estava com drogas, e "deu fuga" apenas porque não possui habilitação; esclarece que, embora já tenha sido preso por tráfico, deixou a prisão dia 05/10/2021, nunca mais se envolveu em nenhum delito, e atualmente tem emprego fixo como serralheiro, é registrado, e possui uma filha de três meses. Interrogado judicialmente, GUILHERME afirmou que no dia dos fatos encontrou o correu em via pública. Ao perceber a presença dos policiais militares se evadiu por estar com a documentação vencida. Asseverou que não sabia da existência de eventuais entorpecentes na posse do correu. Asseverou que não conhece os policiais, já que não é da região.

O acusado John Lenon Pereira da Silva, ouvido na fase inquisitiva às fls. 05, declarou *ipsis litteris* o seguinte: que não se faz acompanhar de advogado e que sua convivente Natália de Souza Oliveira foi cientificada de sua prisão, através do celular (14) 99677-1407, fazendo-se presente nesta Unidade Policial; que é amigo de GUILHERME há muitos anos, bem antes de ambos serem presos; quanto aos fatos, afirma que nesta tarde encontrou GUILHERME por acaso em um campinho na vila onde residem, fumaram um "baseado" e depois o interrogando o convidou para "fazer um peão", o que afirma ser dar uma volta, ver o movimento, e assim fizerem; ocorre que, quando estavam na "Nem", "trombaram" uma viatura, e como GUILHERME não é habilitado, ele "pinoteou", mas foram perseguidos, tendo o interrogando pulado durante o trajeto, até que a viatura bateu na motocicleta e GUILHERME caiu com a mesma; os dois foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado na posse de ambos, absolutamente nada, tanto que nem sabiam o motivo pelo qual estavam sendo presos, acreditavam terem sido conduzidos por direção perigosa. Interrogado judicialmente, JOHN disse que no dia dos fatos era aniversário de sua filha. Teria encontrado com o correu em uma praça. Resolveram sair de motocicleta e ao visualizar uma viatura, Guilherme começou a acelerar a motocicleta já que não possuía habilitação para a condução. Informou que apenas ajudou com a evasão. Disse que foi agredido pelos policiais militares após o acidente. Informou que acreditava estar sendo acusado por direção perigosa. Asseverou que não conhecia os policiais militares.

Pois bem; não vislumbro margem a édito absolutório. Indiscutível que os policiais militares ofereceram o mesmo relato na fase inquisitiva e em Juízo, inexistindo discrepâncias acerca da dinâmica dos fatos. Diante de sobredito panorama, cumpre adiantar que o acolhimento do pleito do Ministério Público é medida de rigor. Verifico que os gendarmes foram uníssomos em afirmar que, durante patrulhamento de rotina, visualizaram que o garupa JOHN ficou nervoso ao notar a guarnição e decidiram abordar a dupla. O corréu GUILHERME passou a correr e foi necessário reforço. Os dois somente foram abordados após fugirem por um bairro e caírem. Em revista pessoal, os policiais apreenderam 45 (quarenta e cinco) eppendorfs de crack e vinte reais.

Quanto à seriedade da versão policial, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que "toda pessoa poderá ser testemunha". Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjética, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição

dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente a apreensão de drogas e dinheiro, realização de laudos periciais, confissão de MATHEUS, etc). Comungo o mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...) Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido” - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto “(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018.

Em idêntico sentir, “(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)” - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistente lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais):

“não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para

admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades". Pontue-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem lastrear o édito penal condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...) " - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

De mais a mais, "é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente" - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

Cumpra destacar que as assertivas dos corréus, que negaram a prática delitiva na Delegacia, são inverossímeis não encontram qualquer amparo na prova produzida nos autos. Apesar da puída insinuação de que os policiais confabularam entre si para incriminar dois inocentes, não há quaisquer indícios de que os militares mentiram ou alteraram os fatos, apenas com o propósito vil e abjeto de prejudicar os corréus.

- No mérito da imputação, cumpre destacar que este Magistrado compreende que o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, interpretado a contrario sensu, permite a análise casuística para se aferir se os entorpecentes são destinados a consumo próprio ou ao tráfico. Referido posicionamento também foi sufragado na Apelação 0045618-90.2015.8.26.0050, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/06/2018. Ainda na seara exegética, também é aplicável o art. 51, inciso I, do mesmo diploma legal, para permitir o balizamento da situação fática perante a tipicidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.

Segundo as diretrizes dos preceptivos em comento, analisando a natureza (crack) e a quantidade de substância apreendida (quarenta e cinco porções de crack), o local e às condições em que se desenvolveu a ação (nervosismo ao notar a viatura e fuga, com queda acidental), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (reincidência específica), indiscutível que as drogas eram destinadas a terceiros.

O Egrégio Colegiado Bandeirante tem decidido, de forma assente e pacífica, que são as especificidades do caso concreto (quantidade e variedade das substâncias apreendidas, local dos fatos, desenvolvimento da conduta, antecedentes policiais/criminais do acusado, dentre outros dados empíricos) que permitem a análise e a conclusão da subsunção do fato ao art. 33 da Lei de Drogas. Em abono, vide os seguintes julgados: Apelação 0002856-33.2016.8.26.0597, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1500370-44.2019.8.26.0484, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1540082-77.2018.8.26.0451, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 2ª Câmara de Direito Criminal, r. 11/05/2020.

Cumpra registrar ainda que, para a caracterização do delito em tela, não se exige a finalidade lucrativa, tampouco que ao agente tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega de estupefaciente a usuários. Invoco como ratio decidendi o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, Editora Juspodium, 5ª edição, p. 1.007/1.012, sem destaques

originais) que, em explanação quanto aos DEZOITO verbos e à tipicidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas, leciona o seguinte:

“Todas as condutas acima mencionadas têm o complemento ainda que gratuitamente, ou seja, sem cobrança de qualquer preço ou valor. Portanto, é de todo irrelevante haver ou não lucro, ou mesmo intuito de lucro. Os vários núcleos verbais constantes do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade (...). Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que para a tipificação desse crime dispensa qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo – o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou o especial fim de agir)”.

No mesmo sentir, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INTENÇÃO DE TRAFICAR 329G (TREZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA APREENDIDOS COM O AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PRÁTICA DE UMA DAS DEZOITO CONDUTAS RELACIONADAS A DROGAS PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO PENAL. 1. "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido - AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 28/08/2019.

Considerando a doutrina e o firme entendimento jurisprudencial, forçosa a conclusão de que a tipicidade do crime de tráfico é extraída das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com todo o mosaico probatório. No caso em tela, a apreensão de diversas porções fragmentadas e embaladas (prontas para serem vendidas), mais a quantia em dinheiro – sem olvidar a reação dos corréus, que demonstrou nervosismo ao notar a polícia e FUGIRAM, permitem concluir, de forma indene de dúvidas, que a conduta amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas.

De mais a mais, o fato de os increpados eventualmente serem usuários de entorpecentes, de per si, não exclui a tipicidade do tráfico. A atividade judicante tem demonstrado que, em diversos casos, os toxicômanos acabam praticando atos de mercancia para sustentar o próprio vício. E, conforme vários precedentes jurisprudenciais, incogitável que a alegação da condição de usuário seja panaceia para afastar a condenação pelo delito do art. 33 da Lei Federal 11.343/2006, ou justificar a automática e irrestrita desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma. No mesmo sentir, da Egrégia Corte Bandeirante, transcrevo as seguintes ementas:

Tráfico ilícito de drogas – Artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas – A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena-base para o mínimo legal – Inviável – A basilar foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,

individualizada e adequada à hipótese dos autos, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, não se cogitando qualquer redução – Aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 – Inadequado – As circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena – Impertinente – A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissível – Não se atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, visto que a pena do réu é superior a 04 anos de reclusão – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido. Apelação 1507305-92.2019.8.26.0228, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, r. 18/07/2020.

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos guardas civis. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Fusão da figura do usuário com a do traficante que faz preponderar a última. Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. A prática do tráfico nas imediações de igreja ou entidade religiosa não está prevista no dispositivo majorante e a sua inclusão importa em analogia "in malam partem", vedada no direito penal. Condenação acertada. Majoração da pena-base em razão da quantidade de tóxico e afastamento do redutor diante da evidência de que a conduta se dava de maneira estabilizada. Fixação do regime fechado. Recursos parcialmente providos, com determinação de expedição de mandado de prisão. Apelação 1502863-69.2019.8.26.0362, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara de Direito Criminal, r. 15/07/2020.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida desclassificação para crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condição de usuário (ou mesmo de viciado) não afasta a atividade de traficante, comprovada nos autos. Circunstâncias da prisão, ausência de emprego lícito. Condenação mantida. Caso de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo. Regime inicial aberto e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos suficientes. Apelo provido em parte. Apelação 0003180-06.2018.8.26.0483, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, r. 06/04/2020.

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação em Primeiro Grau. Recursos interpostos pelos condenados. Preliminar. Vício na denúncia. Não configuração. Peça devidamente assinada pelo Promotor de Justiça. Na hipótese de ausência de assinatura, não existiria nulidade, mas sim mera irregularidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Desclassificação. Reconhecimento da figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Quadro probatório seguro e alinhado à tese acusatória. Laudo químico-toxicológico. Prova oral esclarecedora. Comprovação de que, em atuação conjunta, os réus Adriano e Adriana ocultavam porções de cocaína nas vestes da última, destinadas ao comércio ilícito. Ademais, venderam algumas porções à usuária Flávia Renata. Condição de usuário que não exclui a de traficante. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Desprovimento dos recursos. Apelação 0000025-70.2017.8.26.0631, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, r. 17/12/2018.

Da Corte Cidadã, destaco o seguinte precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 3. A reavaliação dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 23/03/2020.

Com relação à CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA estampada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por ser matéria de ordem pública, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em comento. De acordo com o abalizado escólio